

0000638-42.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06, E ARTS. 12 E 16, § 1º, INC. IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR SUSCITADA POR UM DOS RÉUS. ARGUIDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

0000638-42.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000638-42.2021.8.26.0537

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Roberto Pereira da Cunha e outro

G

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

ROBERTO PEREIRA DA CUNHA e GUILHERMO DE MACEDO CUNHA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput" e parágrafo 1º, e artigo 34, todos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso I, do Código Penal, em concurso material de crimes, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega a terceiros, drogas consistentes em 390,2g de tenanfetamina (conhecida como ecstasy), substância psicotrópica constante da Lista F2 da Portaria SVS/MS nº 344/1998, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 595).

Ainda porque, nas mesmas circunstâncias descritas na denúncia, ROBERTO PEREIRA DA CUNHA e GUILHERMO DE MACEDO CUNHA, qualificados nos autos, tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, constantes da Lista D2 da Portaria SVS/MS nº 344/1998, quais sejam, clorofórmio, acetona, decolorometano, tricloroetileno, sulfato de sódio, ácido sulfúrico e ácido clorídrico, bem como substâncias capazes de serem empregadas na preparação de drogas, constantes da Portaria MJSP 240/19, quais sejam, éter etílico, cafeína, d-manitol, butilamina, iodo e cloreto de amônio (fls. 595/596).

Também porque, nas mesmas circunstâncias descritas na denúncia, ROBERTO PEREIRA DA

CUNHA e GUILHERMO DE MACEDO CUNHA, qualificados nos autos, guardavam aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas sintéticas, como peneiras, funis, colheres, facões, leiteira, pá, martelo, tudo com vestígio da substância psicotrópica MDMA (tenanfetamina), constante da lista F2 da Portaria SVS/MS nº 344/1998, além de tubos de ensaio, eppendorfs vazios, balança e painéis, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 596).

Finalmente porque, nas mesmas circunstâncias descritas na denúncia, ROBERTO PEREIRA DA CUNHA e GUILHERMO DE MACEDO CUNHA, qualificados nos autos, tinham em depósito para vender 18 (dezoito) frascos de trembolona, 22 (vinte e dois) frascos de nandrolona e 40 (quarenta) frascos de testosterona, substâncias anabolizantes constantes da Lista C5 da Portaria SVS/MS nº 344/1998, todos medicamentos sem o registro exigido pelo órgão de vigilância sanitária competente (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) (fls. 596).

Recebida a denúncia e deferido o compartilhamento de provas dos autos nº 1505576-37.2021.8.26.0268 e nº 1505603-20.2021.8.26.0268 (fls. 475/477), os acusados foram citados e ofereceram resposta à acusação (fls. 498/512 e 517/524), prosseguindo-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 557/558). O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, a fim de corrigir erro material e fazer constar os nomes de ambos os réus nos quatro primeiros parágrafos da peça acusatória (fls. 594/599), tendo sido recebido o aditamento e considerada desnecessária nova citação, diante da mera correção de erro material (fls. 601). Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns e 03 (três) testemunhas de defesa, bem como interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. O Ministério Público, em memoriais, requereu a procedência, com a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia (fls. 632/662).

A defesa do acusado Roberto, por sua vez, em memoriais, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, por estar provado que o acusado não concorreu para a infração penal e por não existir prova suficiente para a condenação. Subsidiariamente, postulou a fixação do regime inicial aberto, dada a gravidade do estado de saúde do acusado, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ou, ainda, a suspensão da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal (fls. 665/675).

A defesa de Guilherme, por seu turno, em alegações finais, requereu, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, tendo em vista a indisponibilidade do conteúdo integral dos elementos de prova obtidos do aparelho celular apreendido com Roberto, com a consequente nulidade absoluta da prova obtida a partir do referido aparelho e, ainda, da prova obtida através de print screen de mensagens do aplicativo Whatsapp instalado no celular de Roberto, em razão da possibilidade de edição das conversas e da impossibilidade de contraprova. No mérito, pleiteou a absolvição pela ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, requereu a absolvição da prática do delito previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343/06 pelo reconhecimento do princípio da consunção, bem como a desclassificação do delito previsto no artigo 273, parágrafo 1º-B, do Código Penal, para aquele previsto no artigo 33, "caput", da mesma lei. E, por fim, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do Código Penal (fls. 683/706).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, em relação às preliminares arguidas pela defesa do acusado Guilherme, o caso é de indeferimento, não havendo que se falar em nulidade da prova obtida legalmente do aparelho celular do acusado Roberto, com a devida autorização judicial, apenas em razão da impossibilidade técnica de extração dos dados, conforme informado pela autoridade policial às fls. 607/609.

Ressalte-se que, autorizados judicialmente o manuseio e a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, certo é que as fotografias juntadas no relatório de investigação policial às fls. 256/271 possuem validade como prova e presunção de

veracidade, tratando-se de registro obtido mediante investigação realizada pelos agentes da Polícia Civil, conforme se denota dos detalhados relatórios de fls. 256/271 e 272/276.

Com efeito, a inviolabilidade e idoneidade dos objetos apreendidos são presumidas, de forma que cabia à defesa, caso entendesse terem sido maculados os elementos de prova, a demonstração de quais foram as adulterações a amparar sua alegação de nulidade, o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06, E ARTS. 12 E 16, § 1º, INC. IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR SUSCITADA POR UM DOS RÉUS. ARGUIDA NULIDADE POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E INIDONEIDADE DE PRINT SCREENS EXTRAÍDOS DE APLICATIVO TELEFÔNICO WHATSAPP. DESCABIMENTO. IDONEIDADE DA PROVA PRESUMIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ADEQUADO ACONDICIONAMENTO DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. PROVA INVIOADA. DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE QUE AS TRANSCRIÇÕES SEJAM EFETUADAS POR PERITOS. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS NOS PRESENTES AUTOS QUE NÃO SE TRATAM DE MEROS PRINTS DE CONVERSAS DE APLICATIVO, MAS SIM DE ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO DESEMPENHADA POR AGENTES DA POLÍCIA CIVIL. PREFACIAL RECHAÇADA (...)" (TJSC, Apelação Criminal n. 5000222-75.2022.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara Criminal).

Da mesma forma, igualmente incabível a alegação de fragilidade da prova obtida por meio do aplicativo Whatsapp, diante da suposta possibilidade de edição de diálogos e impossibilidade de contraprova, sendo certo que a jurisprudência é pacífica no sentido de admitir provas produzidas por meio de conversas do referido aplicativo, desde que haja precedente autorização judicial, como ocorreu nos autos, não havendo que se falar em edição das conversas para incriminar Guilherme, não tendo sido apontado qualquer motivo que os policiais civis teriam para o prejudicar.

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DADOS DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA ILÍCITA. SERENDIPIDADE. SÚMULA N. 211/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) - somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há autorização voluntária de interlocutor da conversa (ut, AgRg no HC n. 646.771/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe de 13/8/2021). 2. No caso concreto, consta do acórdão estadual que a devassa no aparelho celular do agravado não foi autorizada em momento algum pela autoridade judiciária competente, não havendo dúvidas, portanto, sobre a ilicitude dessas provas. 3. A tese referente ao encontro fortuito de provas (serendipidade) não foi debatida pelo acórdão recorrido, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 4. Agravo regimental não provido" (AgInt no REsp n. 1.976.850/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim, ausente qualquer indício de que os agentes públicos teriam maculado a prova e, tampouco, realizado qualquer adulteração dos dados extraídos do aparelho celular apreendido, rechaça-se a preliminar arguida.

No mais, o pedido inicial é parcialmente procedente, sendo certo que as demais teses defensivas confundem-se com o mérito e, assim, serão analisadas.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência nº AS9992-1/2021 (fls. 19/32), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33/38), pelo laudo de constatação positivo para tenanfetamina (fls. 47/50), pelos laudos periciais (fls. 250/254, 319/372, 401/452 e 453/460), pelos relatórios de investigação (fls. 256/271, 272/276), pelo compartilhamento das provas produzidas nos autos nº 1505576-37.2021.8.26.0268 e nº 1505603-20.2021.8.26.0268, bem como pelas demais

provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, em relação a ambos os acusados, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em interrogatório judicial, o acusado Roberto afirmou que, na data dos fatos, na sala de seu apartamento, havia duas caixas grandes e três pequenas, todas fechadas, e alguns tambores, mais quatro bombonas, sendo duas de cloro, tudo deixado por seu filho Guilherme, contudo, não sabia que eram materiais para a produção de drogas, já que tudo estava embalado. Disse que seu filho comentou que vendia suplementos alimentares para academias e que estava estudando química, mas não tinha ciência de que eram anabolizantes. Contou que Guilherme retirou as caixas e demais objetos apreendidos da casa onde residia em Itapecerica da Serra e pediu para deixar todo o material em seu apartamento, durante a reforma na casa de Embu, para onde ele iria se mudar. Relatou que, em certa ocasião, o filho deixou uma caixa em seu apartamento e pediu para que a enviasse para uma pessoa de prenome Márcio, revelando que chamou o Uber e mandou a caixa, não tendo mantido contato com Márcio. Aduziu que, na data dos fatos, acordou com a abordagem policial e não chegou a ver seu celular. Informou que, a pedido de Guilherme, foi buscar as caixas na chácara em Itapecerica da Serra, aproximadamente uma semana antes da Polícia cumprir o mandado de busca e apreensão em seu apartamento. Asseverou que, no dia dos fatos, não havia odor forte no apartamento, o que apenas começou quando os policiais quebraram um pote durante a busca. Sustentou que não reconhece as conversas de Whatsapp juntadas aos autos e que não se recorda se o seu aparelho celular possuía aquela tela de fundo e foto no referido aplicativo. Relatou que não forneceu a senha do seu aparelho celular, que foi entregue à Polícia por sua mulher, e que, no momento da busca, ficou sentado no sofá, algemado, quando os policiais localizaram as drogas dentro de gavetas. Acrescentou, por fim, que, após os fatos, não teve mais contato com Guilherme.

O acusado Guilherme, por sua vez, ao ser ouvido em juízo, negou os fatos, declarando que residiu em Itapecerica da Serra por um ano, quando foi vizinho da testemunha Kelli. Afirmou que nunca vendeu, fabricou, nem utilizou drogas sintéticas ou anabolizantes e disse que é recém-formado em engenharia florestal. Informou que todas as substâncias e objetos apreendidos na investigação não lhe pertenciam, não sabendo dizer se pertenciam ao seu pai. Contou que seu pai foi visitá-lo na chácara em Itapecerica da Serra algumas vezes, que conversava com ele por telefone e que trocavam mensagens. Sustentou que conhece uma pessoa de prenome Márcio, que o ajudava com produtos de computador e não com drogas, e que não conhece Samuel. Narrou que, no dia de aniversário de casamento de seu pai, em 10 de abril, foi até o apartamento dele com sua namorada Bárbara para um almoço, ocasião em que não visualizou qualquer material para produção de drogas. Revelou que soube da prisão de seu pai pela mulher dele, Márcia, negando ter entrado em contato com o pai para avisar que a Polícia estava indo para o apartamento dele. Contou que achou estranhos os prints de conversas que estão nos autos, porque ninguém o chama de Guilherme e sim Guilherme, confirmando que, em outubro de 2021, namorava Bárbara. Relatou que não havia produtos ilícitos em sua chácara de Itapecerica da Serra e que não reconhece nenhum material apreendido nos autos. Ressaltou que não reconhece as conversas de Whatsapp que foram juntadas no processo.

Contudo, as versões dos acusados foram desprestigiadas pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A testemunha José Carlos de Andrade, policial civil, em depoimento judicial, declarou que não conhecia os acusados e que a investigação iniciou-se com o recebimento de informação anônima, dando conta de que uma pessoa de prenome Roberto, usando um veículo Renegade branco, estaria praticando tráfico de drogas. Relatou que, localizado o veículo e constatado que era alugado, chegaram à qualificação do acusado Roberto e passaram a investigá-lo, constatando que se dirigia até o Município de Itapecerica da Serra. Afirmou que, diante de fundada suspeita, requisitaram a expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços frequentados pelo investigado, o que resultou na apreensão dos autos, sendo certo que havia suspeitas do envolvimento de outras pessoas nas práticas criminosas, mas não sabiam a qualificação delas. Narrou que, no dia do cumprimento do mandado de

busca e apreensão, deslocaram-se até o apartamento situado em São Bernardo do Campo e, chegando no local, pediram para comunicar o síndico, o qual localizou o acusado Roberto no apartamento de sua namorada, no sétimo andar. Explicou que Roberto, então, acompanhou os policiais até seu apartamento, número 81, franqueando a entrada, e que, logo na entrada, era possível sentir forte odor de produtos químicos. Aduziu que, durante as buscas, foram encontrando muitos petrechos relacionados a laboratório, como garrafas de vidro, balança, tudo com resquícios de produtos químicos, bem como muitos produtos químicos acondicionados em diversos galões e garrafas. Contou que, em revista em um dos quartos, localizou 450 gramas de metanfetamina dentro de uma gaveta. Declarou recordar-se de que o apartamento possuía uma sala, cozinha, banheiro e quarto, mencionando que apenas na sala não havia nada aparente, que a cozinha e o banheiro estavam cheios de materiais de laboratório e produtos químicos, e que, no quarto, onde não havia tanta coisa de laboratório, foi encontrada a droga sintética. Afirmou que a todo momento o acusado Roberto alegava que os objetos pertenciam a seu filho Guilherme, o qual havia percebido que estava sendo investigado e quis tirar os objetos do local que tinha em Itapequerica da Serra. Disse que havia autorização para manuseio e apreensão de celular, tendo sido apreendido o aparelho do acusado Roberto, de onde foram colhidas conversas de Whatsapp entre ele e Guilherme, bem como conversas em um grupo de aplicativo, acerca de drogas. Narrou que o apartamento de São Bernardo do Campo era mobiliado e que o acusado Roberto afirmou ter conhecimento de que seu filho estava instalando no local o laboratório vindo de Itapequerica da Serra. Explicou que Roberto acompanhou toda a revista e que, no momento em que foram localizadas as 450 gramas da droga química, ele estava na porta do cômodo, esclarecendo que a droga somente foi localizada, pois o acusado ficava olhando para a gaveta com frequência. Aduziu que o acusado Roberto afirmava que tudo pertencia a seu filho Guilherme, que era engenheiro químico. Disse que Roberto demonstrava saber que o material era ilícito, mas que não confessou qualquer culpa. Contou que Roberto apenas foi algemado após a localização da droga sintética, um bom tempo após o início das buscas, e no momento de sair do local, para ser conduzido até a Delegacia de Polícia. Declarou que Roberto mencionou que tomava medicamento para diabetes e que, a todo momento, sua namorada Márcia o auxiliou. Esclareceu que, com a informação, houve acompanhamento do veículo Renegade, que, posteriormente, chegou a ser trocado na locadora por outros veículos, que seguiram sendo acompanhados. Afirmou que, em diligências, chegou até a chácara de Itapequerica da Serra, mas não participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão no local, não tendo adentrado na propriedade, mas apenas observado de fora, ocasião em que não presenciou nenhum movimento, além da saída e entrada no portão, não sendo possível visualizar o que acontecia dentro da propriedade. Disse que o próprio Roberto informou que, em Itapequerica da Serra, estava montado o laboratório e, por causa de suspeita de investigação, Guilherme o desmontou, retirou os objetos de lá e os levou para São Bernardo do Campo. Narrou que, segundo Roberto, Guilherme frequentava o apartamento de São Bernardo do Campo. Explicou não ter conhecimento sobre extração de dados do celular de Roberto e disse que ele e sua namorada Márcia não demonstraram indignação acerca dos fatos, evidenciando que tinham conhecimento do laboratório de produção de drogas sintéticas. Informou que localizaram produtos químicos, anabolizantes, insumos, materiais para produção com resquícios de droga e a própria metanfetamina pronta para comércio. Aduziu que foi um colega que analisou o aparelho celular de Roberto e que havia conversas entre ele e Guilherme sobre produção e comércio das drogas, inclusive uma mensagem na data dos fatos, em que o filho tentava alertar o pai de que a Polícia tinha realizado buscas na casa em Itapequerica da Serra.

O policial civil Rafael Palumbo de Abreu, em depoimento judicial, declarou que não conhecia os acusados e que a investigação iniciou-se com o recebimento de informação anônima, mencionando o prenome de Roberto, um veículo branco e caracteres da placa. Relatou que, iniciadas as investigações, constatou tratar-se do acusado Roberto Pereira da Cunha. Afirmou que, então, passaram a seguir seu veículo, observando algumas atitudes estranhas, como carregamento de alguns objetos, o que levou à requisição de expedição de mandado de busca e apreensão, o

que resultou na apreensão de drogas, insumos, produtos químicos, petrechos para fabricação de drogas e anabolizantes. Disse que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na chácara de Itapecerica da Serra. Narrou que havia duas casas no terreno, que, em uma delas, localizaram duas mulheres, as quais explicaram que a outra casa estava vazia e que o antigo morador, Guilherme, havia se mudado havia pouco tempo, acrescentando que nada foi encontrado na residência. Informou que também participou das buscas no imóvel de São Bernardo do Campo, onde foi informado pelo síndico que Roberto estava no apartamento de sua mulher, no andar de baixo. Revelou que lá encontraram o acusado Roberto que os acompanhou até o seu apartamento, no oitavo andar. Contou que os produtos apreendidos estavam espalhados pelo apartamento e que se recorda de ter visto muitas substâncias químicas em barris. Declarou que chegaram ao nome de Guilherme pelas mensagens no celular de Roberto, via aplicativo Whatsapp, em que conversavam sobre a produção, distribuição de drogas e compra de insumos. Mencionou que, nessas conversas, Guilherme dizia ao pai que uma pessoa iria buscar a encomenda, que ele havia lançado um produto novo e, no dia dos fatos, Guilherme enviou mensagem ao pai pedindo para ele sair rapidamente do apartamento porque haviam sido descobertos. Afirmou que havia um grupo em outro aplicativo de mensagens, onde combinavam as entregas, mencionando que, nesse grupo, havia mais pessoas participando. Disse que Roberto acompanhou a busca no apartamento e que a substância tenanfetamina foi encontrada por seu parceiro e que estava em outro cômodo, não presenciando o momento exato do encontro da droga. Sustentou que foram tirados prints das conversas travadas entre os acusados e que os celulares permaneceram na Delegacia de Polícia. Explicou que, posteriormente, ao serem encaminhados para a perícia, não foi possível realizar a extração dos dados dos aparelhos, conforme relatórios que foram juntados aos autos. Informou que, durante as buscas, o acusado Roberto disse que todo o material apreendido era do seu filho Guilherme e que não tinha ciência da ilicitude dos materiais. Aduziu, por fim, que Roberto forneceu a senha de seu aparelho celular e que nada disse sobre as conversas encontradas.

Pois bem. Nada há nos autos que desmereça os relatos dos policiais civis, pois que prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, inclusive com a prova produzida na fase extrajudicial, descrevendo, com detalhes, como se desenrolaram as diligências durante a investigação policial.

Impossível não dar crédito aos relatos deles, que, ao que tudo indica, agiram com lisura, não se podendo desacreditar nos seus depoimentos, visto que localizaram as drogas, os anabolizantes e demais insumos para a produção de drogas na residência do acusado Roberto, onde funcionava o laboratório do seu filho e correu Guilherme. Assim, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ AC. Rel. Synésio de Aquino RDTJRJ 7/287).

Além do mais, não há motivos para se acreditar que queiram incriminar pessoas inocentes, afastando-se a possibilidade de injusta acusação, sobretudo porque os acusados não apontaram quais motivos teriam os policiais para os acusar injustamente.

Afora isso, não produziram as defesas qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Isso porque, a informante Márcia da Silva Carvalho, ao ser ouvida em juízo, afirmou que viveu um relacionamento amoroso com Roberto e que está em processo de anulação do casamento. Disse que, na data dos fatos, não acompanhou a ação policial, apenas comparecendo no local para levar café da manhã e medicamentos para Roberto, que possui diabetes. Contou que, na ocasião, sentiu um odor muito forte, viu que o apartamento estava todo revirado e que os policiais mostraram-lhe uma caixa com algumas 'pedrinhas', não sabendo dizer o que era. Relatou que os policiais chamaram um caminhão para levar todos os objetos embora e que, após seu depoimento na Delegacia de Polícia, os policiais mostraram-lhe todos os itens apreendidos. Aduziu que não frequentava o apartamento de Roberto, que foi até o local raras vezes, sem

observar o que lá havia, e que nunca desconfiou de nada. Informou que, na época dos fatos, Roberto tinha montado seu escritório no apartamento, bem como falava que o filho Guilherme havia deixado algumas coisas guardadas lá. Esclareceu que Roberto contou que Guilherme era engenheiro químico, que fazia suplementos alimentares e que ambos estavam trabalhando na venda dos suplementos. Disse que não sabe com qual frequência Guilherme ia até o apartamento, afirmando que ele nunca morou lá. Contou que Guilherme e sua mulher estiveram no apartamento cerca de dois dias antes dos fatos, ocasião em que passaram em seu apartamento apenas para a cumprimentar. Mencionou que o apartamento estava locado em seu nome e que conversou com Roberto sobre entregar o imóvel, já que ele residia com ela, mas ele não concordou, pois as coisas do filho estavam lá. Revelou que locou o veículo Renegade para uso de Roberto e que teve conhecimento que Guilherme mudou-se para uma chácara em Itapecerica da Serra, na época dos fatos.

A mãe do acusado Guilherme, Solange Bueno Macedo, ouvida como informante em juízo, relatou que Roberto nunca foi um pai presente e só aparecia para pedir ajuda, deixando o filho com problemas financeiros. Afirmou que, em outubro de 2021, Guilherme morava com ela na Cidade de São Paulo, no Bairro São João Clímaco, e que não sabe de nenhuma chácara em Itapecerica da Serra que teria sido alugada ou frequentada por seu filho. Revelou que seu filho é agrônomo por formação e que não estudou química, mencionando, por fim, que Guilherme nunca usou drogas.

A testemunha de defesa Keli Aparecida Silvério Ferreira, em juízo, relatou que é caseira da chácara em Itapecerica da Serra, local em que Guilherme alugou uma casa por aproximadamente um ano. Explicou que residiam no mesmo terreno, mas em imóveis diversos. Afirmou que Guilherme residia no local, permanecendo constantemente lá, sem receber muitas visitas. Disse que nunca presenciou movimentação estranha ou sentiu odor vindo da casa. Informou que é caseira da chácara e que cuida da limpeza do imóvel para locação, aduzindo que nunca percebeu garrações de produtos químicos, balanças ou outros petrechos. Contou que viu Roberto no local uma vez, quando Guilherme apresentou seu pai, e acrescentou que Guilherme disse que trabalhava com plantas, que ele não mora mais na chácara e que presenciou a mudança, mas não se recorda da data.

Dessa forma, vê-se que as testemunhas arroladas pelas defesas nada acrescentaram de relevante ao conjunto probatório, limitando-se a testemunha Keli a declarar nunca ter visto os insumos descritos na denúncia na chácara em que o acusado Guilherme residia, enquanto sua genitora nada mencionou acerca dos fatos e a informante Márcia afirmou que Roberto havia montado seu escritório no apartamento em que os objetos foram apreendidos e lhe dizia que o filho Guilherme havia deixado algumas coisas guardadas no local, o que não afasta a prática dos delitos a eles imputados. Com efeito, conforme relatórios de investigação de 256/271 e 272/276, corroborados pela prova produzida em juízo, após informação anônima sobre a prática de tráfico de drogas por pessoa de prenome Roberto, utilizando um veículo Renegade, cor branca, a Polícia Civil iniciou as investigações, chegando ao acusado Roberto Pereira da Cunha, com residência no município de São Bernardo do Campo, o qual visitava frequentemente uma chácara no município de Itapecerica da Serra.

Ainda de acordo com o relatório de investigação, em cumprimento a mandado de busca e apreensão nos dois endereços, nada de ilícito foi encontrado na chácara de Itapecerica da Serra, porém, no apartamento de São Bernardo do Campo, alugado pelo acusado Roberto, foram localizadas drogas sintéticas, bem como grande quantidade de insumos químicos e petrechos para divisão e embalagem de drogas, com vestígios de substâncias ilícitas, além de anabolizantes, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudos periciais de fls. 47/50, 250/254, 319/372 e 453/460).

Em oitiva judicial, o acusado Roberto negou a participação nos crimes, afirmando que todo o material apreendido era de propriedade do seu filho Guilherme. Por outro lado, o acusado Guilherme, em juízo, alegou que as drogas, produtos químicos, petrechos e anabolizantes foram apreendidos na residência de seu pai, negando qualquer envolvimento, apresentando ambos os acusados narrativas frágeis e nada críveis, cada um buscando responsabilizar o outro pela prática dos delitos. No entanto, a prova coligida revela que o apartamento de São Bernardo do Campo,

locado pelo acusado Roberto em nome de sua esposa Márcia, também era frequentado pelo corréu Guilherme, que tinha livre acesso ao local. Além disso, conforme prova testemunhal, os produtos químicos, anabolizantes e petrechos estavam espalhados por todos os cômodos do imóvel, que exalava um forte odor, característico de produto químico, não sendo crível a versão dos acusados de que não tinham conhecimento do ilícito.

Ao contrário do alegado pela defesa do acusado Guilherme, foram produzidas provas suficientes a demonstrar que ele frequentava o apartamento do pai, conforme prova oral produzida em juízo, revelando Roberto em seu interrogatório que o filho havia retirado todo o material apreendido da casa onde residia em Itapecerica da Serra e deixado em seu apartamento.

Outrossim, de acordo com a informante Márcia, Guilherme e sua namorada estiveram no apartamento do pai, dois dias antes da Polícia cumprir o mandado de busca e apreensão, para levar algumas coisas para o apartamento, já que Guilherme tinha se mudado da chácara em Itapecerica da Serra, o que confirma que frequentava o local. Assim, ao aduzir que não esteve no apartamento na semana antecedente aos fatos, cabia à defesa de Guilherme apresentar as provas do alegado, como, por exemplo, imagens da câmera de segurança, o que somente foi aventado em alegações finais, aduzindo que caberia ao Ministério Público requerer tal diligência.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL (RÉ PRESA). TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA E CRACK (3.449,2KG - TRÊS QUILOS, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE GRAMAS E DOIS DECIGRAMAS E 350G - TREZENTOS E CINQUENTA GRAMAS, RESPECTIVAMENTE). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NEGATIVA DA AUTORIA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL A TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A QUEM ALEGA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E UNÍSSONOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA NARCOTRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (TJ-SC - ACR: 232398 SC 2009.023239-8, Relator: Marli Mosimann Vargas, Data de Julgamento: 05/03/2010, Primeira Câmara Criminal).

Ademais, nos termos da declaração da informante Márcia, Roberto, seu marido, havia contado que não podia devolver o apartamento que alugava, pois seu filho Guilherme estava guardando alguns objetos no local. Na oportunidade, Roberto contou que o filho era engenheiro químico e fabricava suplementos alimentares, bem como explicou que ambos estavam trabalhando na venda desses suplementos.

Na mesma linha, através do manuseio do aparelho celular do acusado Roberto, devidamente autorizado pela decisão que deferiu a busca e apreensão, foi constatada a participação de ambos os acusados, pai e filho, nas práticas delitivas, diante da existência de vários diálogos acerca da produção, distribuição e valores de venda das drogas, conforme relatório de investigação de fls. 256/271.

Apurou-se que o acusado Guilherme, formado em engenharia, era o responsável pela fabricação e produção das drogas, bem como pela organização do comércio dos ilícitos, conforme se extrai das mensagens trocadas entre ambos (fls. 260/268), enquanto seu pai Roberto era responsável por transportar, distribuir e armazenar as drogas e os insumos para sua fabricação.

Ainda de acordo com os prints, efetuados pelos policiais, das mensagens trocadas via aplicativo Whatsapp entre os réus, constatou-se que Guilherme, ciente de que era alvo de investigação policial, pretendia retirar todo o material apreendido do apartamento do pai (fls. 267) e que, na data dos fatos, tentou avisá-lo de que a Polícia esteve na chácara para cumprir mandado de busca e apreensão e que era necessário retirar todos os materiais do apartamento de São Bernardo do Campo (fls. 271).

Verificou-se, inclusive, das referidas mensagens, que eles passavam-se por uma empresa de cosméticos para a contratação de caminhões para transporte das drogas e demais substâncias e, ainda, que utilizavam veículos de aplicativos para a mesma finalidade, sem o conhecimento dos motoristas, tudo a revelar que comercializavam as drogas.

Além disso, o tráfico de drogas ficou evidente na mensagem enviada por Roberto



dizendo "Tem um cara que paga 9k no kg md velho", ao que Guilherme responde "Ah n posso agora correr risco" (fls. 263). E, ainda, Roberto diz "O cara de Moema está querendo produto, tipo 2kg do m" e Guilherme responde "Eu sei mas agora n tem como eu vender pra cliente novo...Depois corremos risco de novo com cliente novo" (fls. 263).

Assim, devidamente demonstrado que ambos os acusados estavam envolvidos nas práticas delitivas, não há que se falar em ausência de provas quanto à participação de qualquer um deles, sendo certo que o fato de não ter sido encontrado qualquer material ilícito na propriedade de Guilherme não o isenta da responsabilidade penal, diante de todo o conjunto probatório, a revelar que ele desmontou o laboratório que havia no local porque já tinha conhecimento de que era alvo de investigação.

Vale destacar que, embora Guilherme tenha sugerido em audiência que não era a mesma pessoa que trocou mensagens com Roberto, já que as pessoas o chamam de Guilherme e não Guilherme, ele confirma em seu interrogatório judicial que residiu em Itapeceira da Serra por um ano e que mantinha um relacionamento amoroso com Bárbara na época dos fatos, o que demonstra que era ele mesmo quem trocava mensagens com o corréu Roberto, já que o nome de Bárbara, inclusive, foi mencionado nas conversas.

Dessa forma, caracterizada a prática do delito de tráfico de drogas por ambos os acusados, diante dos depoimentos dos policiais civis, bem como da significativa quantidade de porções de droga (quase 400 gramas de ecstasy), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 33/38, laudo de constatação positivo para tenanfetamina (fls. 47/50) e laudo de exame químico-toxicológico positivo para metilenodioximetanfetamina - ecstasy (fls. 250/254), encontrada no interior da residência do acusado Roberto, frequentada pelo seu filho Guilherme, demonstrado que ambos os denunciados tinham em depósito e guardavam, para fins de comércio espúrio, tenanfetamina.

Cabe ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, estatuído no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 imputado aos réus, não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância, não se exigindo a venda para consumação do delito.

Da mesma forma, demonstrada a prática do crime descrito no artigo 33, parágrafo 1º, da Lei nº 11.343/06, por ambos os acusados, tendo em vista que, no local dos fatos, foram apreendidos insumos utilizados para fabricação, síntese e preparação de drogas, constantes da lista D2 da Portaria SVS/MS nº 344/1998, como clorofórmio, ácido sulfúrico, tricloroetileno, acetona, diclorometano, ácido clorídrico, éter etílico e sulfato de sódio, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 33/38 e laudo pericial de fls. 401/452 (com cópia às fls. 319/372), o que foi confirmado pela prova oral produzida em juízo..

Ao contrário do alegado pela defesa do acusado Guilherme, infere-se que o crime de tráfico drogas, disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e a conduta de de possuir insumos para a produção ou transformação de drogas, prevista no artigo 33, parágrafo 1º, da mesma lei, mostram-se crimes inconcussos, praticados de forma autônoma, não se podendo cogitar de consunção.

No caso em tela, têm-se situações distintas, tendo em vista a apreensão de grande quantidade de insumos e produtos químicos, que constituem matéria prima para a produção de drogas (conforme laudo de fls. 401/452), aptas a vulnerar o tipo penal preconizado no artigo 33, parágrafo 1º, da Lei nº 11.343/06, de modo que cada uma das condutas ofende um tipo penal distinto, de sorte que a reprovação de cada qual há de ser penalizada individualmente.

Neste sentido:

"REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE INSUMOS, PRODUTOS QUÍMICOS, MÁQUINÁRIOS, INSTRUMENTOS E OBJETOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. Artigos 33, caput, 33, §1º e 34, todos da lei nº 11.343/06. Contexto fático anterior que permitiu a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, justificando a mitigação ao direito à inviolabilidade do domicílio. Mérito. Impossibilidade de aplicação do princípio

da consunção. Prova que não evidencia a ocorrência de desdobramento lógico entre as condutas, ou que uma delas configure uma etapa de execução da outra. Autonomia das condutas evidenciada. Análise razoável e ponderada da prova que impede o reconhecimento de erro judiciário. Teses que, ademais, já foram analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE" (TJSP, Revisão Criminal nº 0008632-20.2020.8.26.0000; Rel. Des. Camargo Aranha Filho, 8º Grupo de Direito Criminal, j. 01/04/2022).

No entanto, o reconhecimento do delito de posse de instrumentos para a produção de drogas, previsto no artigo 34 da Lei nº 11.363/06, é inviável. Utensílios como peneiras, funis, colheres, facões, leiteira, pá, martelo, tubos de ensaio, eppendorfs vazios, balança de precisão e panelas, não podem ser considerados maquinário ou instrumento apto a tipificar a conduta prevista no referido tipo penal, uma vez que se destinam apenas à mera pesagem, divisão e embalagem de drogas, ainda que em porções individuais, visando facilitar a venda, distribuição e consumo. Neste sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação Criminal - Artigos 33, caput, e 34, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Delito de tráfico ilícito - Apreensão de 7 sete porções (36,5 gramas) e um tablete (492,8 gramas) de maconha; 40 invólucros com cocaína (105 gramas), uma sacola plástica e um pote contendo, respectivamente, 51,2 e 129 gramas da mesma droga - Materialidade, autoria e culpabilidade, incontroversas, ausente impugnação quanto à condenação, na parcela - Pleito de absolvição ou de aplicação do princípio da consunção quanto ao delito conexo (art. 34, da Lei de Drogas) - Necessidade - Réu que guardava, em sua moradia, além dos entorpecentes referidos, impressões coloridas ostentando personagens de histórias em quadrinhos; microtubos e frascos plásticos; tampas de pressão; pequenos vidros vazios; potes e saquinhos de material sintético; embalagens de papel para cigarros; um liquidificador e uma faca contendo sujidades de coloração branca - Delito subsidiário ao crime de tráfico que, na espécie, por este deve ser absorvido, pois, no mesmo contexto fático, o réu armazenava as drogas e os petrechos utilizados para a divisão daquelas em porções individuais (e não à efetiva fabricação, produção ou preparo das substâncias ilícitas, que envolveria a transformação química das drogas) - Precedentes - Dosimetria (tráfico) - Penas motivadas e individualizadas - Regime fechado, único adequado in casu - Recurso provido." (TJSP; Apelação Criminal 0103125-38.2017.8.26.0050; Rel. Des. Juvenal Duarte; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2018).

Assim também decidiu o E.Superior Tribunal de Justiça:

"... Há nítida relação de subsidiariedade entre os tipos penais descritos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006. De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório. Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. No caso, referida análise prescinde do reexame de fatos, pois da leitura da peça acusatória, verifica-se que a droga e os instrumentos foram apreendidos no mesmo local e num mesmo contexto, servindo a balança de precisão e a serra/alicate de unha à associação que se destinava ao tráfico de drogas, não havendo a autonomia necessária a embasar a condenação em ambos os tipos penais simultaneamente, sob pena de bis in idem. 4. Salutar aferir, ademais, quais objetos se mostram aptos a preencher a tipicidade penal do tipo do art. 34 da Lei de Drogas, o qual visa coibir a produção de drogas. A meu ver, deve ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sob pena de a posse de uma tampa de caneta - utilizada como medidor -, atrair a incidência do tipo penal em exame. Relevante, assim, analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela. No caso dos autos, além de a conduta não se mostrar autônoma, verifico que a apreensão

de uma balança de precisão e de um alicate de unha não pode ser considerada como posse de maquinário nos termos do que descreve o art. 34 da Lei de Drogas, pois referidos instrumentos integram a prática do delito de tráfico, não se prestando à configuração do crime de posse de maquinário. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para excluir a condenação dos recorrentes Márcia Regina Millezi e Francisco Luís Alves de Lima pela prática do delito do art. 34 da Lei de Drogas." (REsp 1196334/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013).

Pelo exposto, tendo em vista que o fato narrado na denúncia não constitui o crime previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343/06, a absolvição neste ponto, pela atipicidade da conduta, é medida que se impõe.

Por fim, também demonstrada a prática do delito previsto no artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso I, do Código Penal pelo acusados, diante da apreensão de 80 (oitenta) frascos de substâncias anabolizantes, tais como trembolona, nandrolona e testosterona, constantes da lista C5 da Portaria SVS/MS nº 344/1998, sem o registro exigido pelo órgão de vigilância sanitária competente - ANVISA, conforme demonstrado pelo laudo pericial de fls. 453/460.

Vale destacar que a expressiva quantidade de frascos apreendidos, em conjunto com todos os demais produtos ilícitos encontrados no local, não deixa dúvidas quanto à finalidade de venda das substâncias anabolizantes.

Por sua vez, a defesa do acusado Guilherme pleiteia pela aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tanto em relação ao crime de tráfico de drogas, como em relação ao delito previsto no artigo 273 do Código Penal, em respeito ao princípio da proporcionalidade da lei penal.

Anoto-se que, de fato, é certo que, com o advento da Lei nº 11.343/06, no delito de tráfico e nas formas equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No entanto, a expressiva quantidade de droga (ecstasy), anabolizantes, produtos químicos, petrechos e insumos para a produção e preparação de drogas, tudo a aparelhar um verdadeiro laboratório de drogas, é incompatível com a figura privilegiada, sendo inviável reconhecer que se tratem de meros traficantes eventuais, sendo certo que os acusados agiam em conjunto, em esquema que envolvia outros agentes, como se percebe das conversas pelo aplicativo Whatsapp e pelo próprio depoimento do acusado Roberto, ao afirmar que, a pedido de Guilherme, enviou uma caixa que estava no apartamento para uma pessoa de prenome Márcio. Não bastasse, ficou evidente o vínculo dos acusados com o tráfico de drogas em larga escala, já que contratavam motoristas através do aplicativo Uber para realizarem as entregas das encomendas, sendo clara a habitualidade no crime, sendo certo, ainda, que Guilherme afirma nas conversas com o pai que tinha a intenção de comercializar drogas no exterior, na Bolívia (fls. 266).

Sobre o tema, já decidiu a jurisprudência que:

"(...) 4. A elevada quantidade de droga apreendida, a saber, quase dez quilos de maconha, acondicionada em nove tabletes, provenientes do Estado de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, é circunstância que impede o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime. 5. De se ver, que a "mens legis" da causa de diminuição de pena seria alcançar aqueles pequenos traficantes, circunstância diversa da vivenciada nos autos, dada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, com alto poder destrutivo. 6. Ordem denegada" (STJ, HC 149.697/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 10.05.11, DJ 23.05.11).

No mais, ainda que assim não fosse, o acusado Roberto não preenche os requisitos legais acima elencados e descritos no artigo 33, parágrafo 4º, da referida lei, não se aplicando a causa de diminuição de pena, à vista da comprovada reincidência (processo nº 0005842-17.2020.8.26.0565 - fls. 715).

Por outro lado, em relação ao delito do artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso I, do Código Penal, em sessão plenária ocorrida em 24/03/2021, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a pena cominada para a conduta de importar medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em razão da desproporcionalidade da pena cominada, maior do que aquelas cominadas para crimes

mais graves, decidindo-se reprimar a pena cominada no artigo 273 antes da nova redação dada pela Lei nº 9.677/98 para o inciso I do parágrafo 1º-B do mesmo artigo, firmando-se a seguinte tese de repercussão geral:

"É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/1998 - reclusão de 10 a 15 anos - à hipótese prevista no seu parágrafo 1º-B, inciso I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica reprimado o preceito secundário do artigo 273, na redação originária - reclusão de um a três anos e multa" (RE 979.962/RS, j. 24/03/21). Constata-se que os crimes acima definidos foram praticados em concurso material de infrações, pois os acusados, mediante mais de uma ação, praticaram crimes distintos, aplicando-se cumulativamente as penas.

Assim sendo, satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos descritos na denúncia, impõe-se o desfecho de procedência parcial do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Roberto Pereira da Cunha:

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, por infração ao artigo 33, "caput", e parágrafo 1º, desta lei, considerando a expressiva quantidade de droga (ecstasy), anabolizantes, produtos químicos, petrechos e insumos para a produção e preparação de drogas, tudo a aparelhar um verdadeiro laboratório de drogas, fixo-lhe a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cada crime.

Caracterizada a reincidência (processo nº 0005842-17.2020.8.26.0565 - fls.

714/715), reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para cada crime, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso I, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Caracterizada a reincidência (processo nº 0005842-17.2020.8.26.0565 - fls.

714/715), reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora obtidas, obtendo 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 1.371 (mil, trezentos e setenta e um) dias-multa.

Guilherme de Macedo Cunha:

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, por infração ao